

1500216-53.2020.8.26.0593

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... local dos fatos é conhecido como ponto de tráfico. A denúncia anônima recebida via COPOM descrevia as vestes dos indivíduos, que coincidiam com as dos réus e do adolescente. Não viu os réus e o adolescente ingressarem no terreno. A droga foi encontrada no terreno com o apoio do canil, uma vez que nos casos de tráfico é normal vistoriarem áreas próximas.

A testemunha ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1500216-53.2020.8.26.0593 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500216-53.2020.8.26.0593

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY MUNIZ DE AMORIM e outros

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

WESLEY MUNIZ DE AMORIM, JOÃO PEDRO SPINDOLA DA SILVA e FELIPE FAGUNDES DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, porque, em 10 de junho de 2020, por volta de 11h45, na Rua José Pelegrini nº 230, Bairro Alto Cafezal, nesta cidade de Marília, em concurso, agindo com unidade de propósitos, envolvendo o adolescente L. F. R. S., traziam consigo e guardavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para entrega ao consumo de terceiros, 266,41 gramas de Cannabis Sativa L (maconha), divididos em 54 porções, e 16,18 gramas de cocaína na forma de crack, divididos em 159 microtubos (cf. laudos de constatação e químico-toxicológico acostados aos autos).

Presos em flagrante delito (fls. 5), lhes foi deferida a liberdade provisória (fls. 127/129). Os réus foram notificados (fls. 256, 258 e 260) e apresentaram defesa preliminar (fls. 245/254, 261/270 e 274/276). A denúncia foi recebida em 30/9/2020 (fls. 278/280) e os acusados foram citados (fls. 334, 338 e 346).

Em audiência de instrução realizada em 25/8/2021, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e três testemunhas de defesa e os réus foram interrogados (fls. 346/348 e mídia).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a parcial procedência da ação, com a condenação de WESLEY, a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas em relação a FELIPE e a absolvição de JOÃO PEDRO. Quanto à WESLEY, na dosimetria, postulou a fixação da pena acima do mínimo legal, em razão da natureza de parte das drogas (crack), e apontou para a ausência de circunstâncias agravantes e a presença da atenuante prevista no artigo 65, III, "d", do CP, devendo incidir a causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei de Drogas. Inaplicável a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, haja vista ter passagem por ato infracional análogo ao crime de tráfico, devendo ser fixado o regime inicial fechado. Por fim, em relação à FELIPE, ofereceu proposta de transação penal, pleiteando designação de audiência preliminar e a restituição do dinheiro apreendido com ele (fls. 582/587).

A Defesa do réu WESLEY requereu sua absolvição, ante a fragilidade do conjunto probatório, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP. Em caso de condenação, pleiteou a aplicação da pena em seu patamar mínimo, afastando-se a causa de aumento prevista no inciso VI do artigo 40, da Lei nº 11.343/06, e aplicando-se a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da mesma Lei. Por fim, pugnou pela fixação do regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 591/601).

A Defesa do réu JOÃO PEDRO requereu sua absolvição, pela manifesta inocência e ausência de provas, nos termos do artigo 386, II, V e VII, do CPP. Em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena no mínimo legal e concessão do direito de apelar em liberdade (fls. 604/612).

A Defesa do réu FELIPE requereu a improcedência da ação penal, com sua absolvição (fls. 613/618).

É o relatório. DECIDO.

A acusação é parcialmente procedente.

A existência material do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, isto é, a realização do tipo penal em todos os seus elementos, restou comprovada pelas provas colhidas durante a instrução, tais como o auto de prisão em flagrante (fls. 5), boletim de ocorrência (fls. 19/23), auto de exibição/apreensão (fls. 24/25), fotos (fls. 26/32), laudos de constatação provisória e de exame químico-toxicológico – definitivo (fls. 34/39 e 213/216), estes atestando a natureza das substâncias apreendidas (cocaína e maconha), relatório final da D. Autoridade Policial (fls. 219/221), e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa somente em relação ao acusado WESLEY.

A testemunha Luís Alberto Silva, policial militar, declarou que foram acionados via COPOM, sendo que o denunciante informava que havia quatro indivíduos exercendo o tráfico, próximo a uma moita de bambu. Deslocaram-se até o local e, ao avistar a viatura, WESLEY saiu correndo, mas foi perseguido e detido. Com ele, foram localizados uma porção de maconha, três pinos de crack e R\$ 10,00. Com FELIPE, foram localizadas a quantia de R\$ 80,00 em dinheiro e uma porção de maconha. Com JOÃO PEDRO, nada foi encontrado. Com o adolescente, foi encontrada a quantia de R\$ 150,00. Com o apoio do canil, em terreno baldio próximo ao local em que estavam, foi encontrada uma sacola preta contendo quarenta e nove invólucros de maconha, vinte e dois microtubos de cocaína, cento e trinta e quatro microtubos de crack e R\$ 75,00 em dinheiro, divididas em notas diversas. O local em que os réus estavam

ficava uns 20 metros de distância do terreno baldio. O local dos fatos é conhecido como ponto de tráfico. A denúncia anônima recebida via COPOM descrevia as vestes dos indivíduos, que coincidiam com as dos réus e do adolescente. Não viu os réus e o adolescente ingressarem no terreno. A droga foi encontrada no terreno com o apoio do canil, uma vez que nos casos de tráfico é normal vistoriarem áreas próximas.

A testemunha Rafael Cardoso de Oliveira, policial militar, declarou que foram acionados via COPOM, sendo que o denunciante informava que havia quatro indivíduos vendendo entorpecentes. Deslocaram-se ao local e, no momento em que saíram da viatura, WESLEY empreendeu fuga, vindo a ser perseguido e abordado pelo depoente. Durante a fuga, ele dispensou um invólucro contendo maconha e no seu bolso foram encontrados dinheiro e mais algumas porções de droga. Com o FELIPE foram encontrados R\$ 80,00 e uma porção de droga. Com o JOÃO PEDRO nada foi encontrado. Com o apoio do canil, encontraram uma sacola preta num local próximo, com várias porções de maconha, cocaína, crack e mais R\$75,00. O terreno baldio fica uns 20 ou 30 metros do local da abordagem. Acrescentou que WESLEY é conhecido nos meios policiais por envolvimento com o tráfico. Um dos indivíduos disse que estava indo trabalhar e que tinha carteira assinada no "Supermercado Atacadão". Por fim, esclareceu que FELIPE era quem estava indo trabalhar e, inclusive, estava atrasado.

A testemunha Alcione Cristina da Cruz, vizinha de JOÃO PEDRO, disse que ele trabalha com o pai e também em um bar. Nunca ouviu falar nada dele e nunca teve problema com ele. Ele trabalha de segunda a sábado, como ajudante do pai dele, numa construtora.

A testemunha Danilo Marques disse que trabalha junto com JOÃO PEDRO e o pai dele. Nunca viu nada de errado. Trabalha há 9 anos com o pai dele. JOÃO PEDRO sempre foi uma boa pessoa.

A informante Sandra Aparecida dos Santos Alves, amiga íntima da família de FELIPE, disse que ele é muito trabalhador e educado, fez o tiro de guerra e frequentava as festas na casa dela junto com a namorada. Trabalha há 4 anos no Atacadão. Não sabe de nada que o desabone. Após os fatos, FELIPE casou e teve um filho.

O réu Wesley Muniz de Amorim alegou que, juntamente com o adolescente L. F., foi até o local do fato para usar droga. Encontrou o rapaz que vende drogas e, então, as adquiriu. Quando a viatura policial surgiu, tentou empreender fuga, andando, porque estava com as porções no bolso e ficou com medo. A droga apreendida em seu poder seria para uso próprio e do adolescente. Estava próximo a um bambuzal, que é distante do terreno baldio onde o canil encontrou a droga. Ele estava junto com os demais réus no momento em que a polícia apareceu.

O réu João Pedro Spindola da Silva disse que estava retornando da casa de sua namorada para sua casa, que fica na mesma rua em que ocorreu a abordagem, e uns 400 metros da sua casa viu seus conhecidos, FELIPE, WESLEY e o adolescente, e parou para cumprimentá-los, momento em que os policiais chegaram e os "enquadraram". Não viu nenhum entorpecente em poder deles. O terreno baldio fica a aproximadamente cem metros do local da abordagem. A droga encontrada no terreno baldio somente lhe foi exibida na delegacia.

O réu Felipe Fagundes dos Santos disse que seu pai havia feito um depósito em sua conta bancária. Dirigiu-se à agência bancária situada na Av. João Ramalho, onde sacou o dinheiro, em torno de R\$ 120,00, que seria destinado ao pagamento de conta de água e aquisição de alimentos. Retornava de bicicleta e encontrou os demais réus e o adolescente. Parou, então, para conversar com eles, momento em que os policiais os abordaram. Estava próximo ao horário de ir trabalhar, pois entrava às 14h no serviço. Em seu poder foi encontrada uma porção de maconha, que era para seu uso pessoal. Foram abordados próximo a uma árvore, sendo que o terreno baldio onde foram encontradas as drogas fica um pouco longe. Trabalha no "Supermercado

Atacadão" desde 2017.

Pois bem. Da análise do conjunto probatório coligido aos autos, conclui-se não ser possível vincular a propriedade das drogas apreendidas no terreno baldio aos réus. Os policiais não presenciaram qualquer um deles ingressando no local, sendo, nesse ponto, insuficiente a prova.

Entretanto, restou demonstrado que o réu WESLEY trazia consigo entorpecentes e dinheiro.

Não obstante a negativa de WESLEY e os argumentos defensivos, a atividade delitiva foi corroborada pela existência de elementos bastantes que demonstram que ele era proprietário das drogas e que as porções de entorpecentes apreendidas com ele se destinavam ao tráfico ilícito de drogas, nos termos do art. 52, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da ocorrência concomitante das seguintes circunstâncias: a) o relato harmônico dos policiais de que receberam denúncia anônima de que 4 (quatro) indivíduos estariam praticando o comércio ilícito de drogas e, ao chegarem ao local indicado, visualizaram os indivíduos, momento em que o réu WESLEY tentou fugir, jogando as drogas no chão; b) a variedade e a quantidade de droga apreendida, qual seja, 3 porções grandes e 1 porção pequena de maconha e 3 microtubos de cocaína; c) a importância de R\$ 10,00 encontrada com ele, como é comum nas apreensões do comércio ilícito.

Como se vê, ao contrário do que aduz a Defesa de WESLEY, a acusação encontra respaldo probatório nos autos e é suficiente para a condenação, já que os relatos dos policiais foram harmônicos e coesos.

Em relação aos testemunhos dos policiais, destaco que seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, prestam conta de suas atividades, não havendo qualquer motivo para que incriminassem falsamente o acusado.

Apenas para registrar, é prescindível para a caracterização do delito em análise que o réu seja flagrado em efetivo comércio, posto que o tráfico ilícito de entorpecentes é crime de ação múltipla, bastando a identificação na ação do acusado de apenas um dos núcleos elencados no tipo penal.

Vale ressaltar, ainda, que em poder do réu WESLEY havia 3 porções grandes e 1 porção pequena de maconha, 3 microtubos de cocaína e R\$ 10,00. Essas porções grandes de maconha pesavam 56,94 gramas, quantidade expressiva que poderia ser fracionada em mais de 50 porções, se levarmos em conta que os 2 invólucros de maconha apreendidos pesavam 1,82 gramas (fls. 37). Portanto, não há como considerar que os entorpecentes encontrados com ele se destinavam ao uso próprio, pois a quantidade não é compatível com a condição de usuário.

Desta forma, a prova coligida é robusta e demonstra que houve a completa subsunção da conduta do réu WESLEY ao tipo penal do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

No que diz respeito à causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei Drogas, não restou comprovado que o réu envolveu o adolescente no delito.

Embora WESLEY tenha dito em Juízo que foi até o local dos fatos com o adolescente L. F., suas versões são contraditórias, pois na fase policial afirmou que o encontrou somente no local dos fatos (fls. 14/15). Por sua vez, o adolescente L. F. declarou na delegacia que tinha ido ao local comprar maconha para uso próprio e que os réus também estavam lá (fls. 9). Outrossim, no momento da abordagem policial, não foi encontrada droga em poder do adolescente, vindo a ser posteriormente absolvido da imputação da prática de tráfico de entorpecente (fls. 524/527 e 532).

Com relação à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, destaco a impossibilidade de aplicação na situação em tela. Verifico que, além da quantidade e da nocividade dos entorpecentes apreendidos, o réu ostenta antecedentes infracionais e, inclusive, cumpriu medidas socioeducativas por atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes (fls. 72). Embora tais feitos da Vara da Infância e Juventude não permitam a valoração negativa na primeira fase da dosimetria ou signifiquem reincidência (artigos 59 e 64 do Código Penal c/c Súmula 444 do STJ), são dados idôneos para afastar a minorante, porquanto comprovam a dedicação às atividades delituosas desde a adolescência e a habitualidade em praticar fatos tipificados como crime. Nesse sentido:

Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Inaplicabilidade da redutora do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas em razão da dedicação do acusado às atividades criminosas, conforme atos infracionais praticados quando adolescente. Precedentes do STJ. Substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Recurso improvido. – Apelação nº 1500768-90.2020.8.26.0472, Rel. Reinaldo Cintra, 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 28/2/2021.

“(...) Considerando que um dos requisitos para concessão da benesse é o agente não se dedicar a atividades criminosas, é certo que o envolvimento do paciente quando menor em atos infracionais, inclusive relacionados ao crime de tráfico, é elemento idôneo a afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demonstra uma propensão do agente a práticas criminosas (...)” - AgRg no HC 560.742/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª T., DJe 04/05/2020.

“(...) A existência de registros de atos infracionais é apta a justificar a negativa da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, por indicar a dedicação do réu à prática delituosa, nos moldes admitidos pela jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, inexistindo ilegalidade a ser sanada quanto ao ponto (...)” - AgRg no HC 544.100/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 14/02/2020.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade dos agentes, inevitável a condenação de WESLEY.

Por outro lado, em relação aos demais réus, não ficou comprovado que eles estivessem praticando o tráfico de drogas.

Da análise de todas as provas colhidas durante a instrução, verifica-se que com o acusado FELIPE foram encontrados uma porção de maconha e R\$ 80,00 em dinheiro.

Ele afirmou, em Juízo, que a droga era para uso pessoal e o dinheiro havia sacado numa agência bancária próxima, para pagamento de conta de água e compra de alimentos. Disse, ainda, que a abordagem ocorreu próximo do horário de ir trabalhar no “Supermercado Atacadão”.

A versão de FELIPE é reforçada pelo relato do policial Rafael de que, no momento da abordagem, ele teria dito que trabalhava no “Supermercado Atacadão” e que estava atrasado para entrar no serviço.

Outrossim, o montante de droga apreendida com ele é compatível com a condição de usuário.

Neste contexto, em razão da falta de outros elementos indicativos de que FELIPE

estivesse agindo em concurso com WESLEY na comercialização de drogas, necessária a desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes para o de mera posse para uso próprio.

Quanto ao réu JOÃO PEDRO, a absolvição é medida que se impõe.

Com efeito, nada foi apreendido em seu poder e das provas colhidas nos autos não há como se inferir qualquer envolvimento dele com o tráfico de drogas.

A condenação pressupõe certeza absoluta ou, ao menos, uma soma de fortes indícios que dêem base sólida à imputação. Se a prova colhida em Juízo é precária no sentido de comprovar que o réu concorreu para a infração penal, impõe-se a absolvição.

Passo, então, a dosar a pena para o réu WESLEY, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a Lei nº 11.343/2006 prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A culpabilidade, entendida como a reprovabilidade da conduta, não ultrapassa o normal desvalor do crime. Além disso, não há nos autos elementos que lhes sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem a majoração da pena-base.

Na segunda fase, não há circunstância agravante a ser ponderada. Verifico que incide a atenuante prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal, porque o réu era menor de 21 anos de idade na data dos fatos (fls. 49). Contudo, não pode reduzir a pena abaixo do patamar mínimo legal.

Na derradeira etapa, verifico que não há causas de aumento ou de diminuição da pena, devendo a reprimenda permanecer como dosada na primeira fase. Conforme já explanado acima, deixo de aplicar a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, bem como a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da mesma Lei.

Torno, assim, final a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Pelas condições econômicas do réu, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

- CONDENAR o réu WESLEY MUNIZ DE AMORIM, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal;
- DESCLASSIFICAR a conduta imputada ao réu FELIPE FAGUNDES DOS SANTOS, qualificado nos autos, para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006 e, em consequência, mediante a proposta ofertada pelo Ministério Público, reconhecer a aplicabilidade de medidas despenalizadoras previstas na Lei nº 9099/95; e
- ABSOLVER o réu JOÃO PEDRO SPINDOLA DA SILVA, qualificado nos autos, da imputação da prática do crime tipificado no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código

de Processo Penal.

A pena privativa de liberdade imposta ao réu WESLEY deve ser cumprida em regime inicial fechado. Tratando-se de crime equiparado a hediondo, que causa consequências gravíssimas à sociedade, alimentando o crime organizado e destruindo as famílias dos dependentes químicos, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, a fim de que sejam atingidos os objetivos de prevenção geral e específica da punição criminal.

Anoto que, diante da pena fixada, é inviável a sua substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme art. 77 do mesmo diploma legal.

Ante a ausência de elementos concretos a embasar a necessidade da prisão preventiva e considerando que permaneceu solto durante todo o processo, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Em face da condenação supra, o réu WESLEY arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs. Todavia, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade permanecerá sobrestada.

Quanto ao réu FELIPE, transitada em julgado a sentença, voltem os autos conclusos para deliberação acerca do requerimento ministerial de fls. 587.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Comunique-se a autoridade policial para que destrua as substâncias apreendidas, contraprovas e eventuais embalagens, apetrechos ou materiais utilizados para acondicionamento, nos moldes do artigo 72 da Lei nº 11.343/06.

Ademais, decreto a perda do dinheiro apreendido com o réu WESLEY (R\$ 10,00), bem como o dinheiro apreendido no terreno baldio (R\$ 75,00), constantes no auto de exibição/apreensão de fls. 24/25 e depósito judicial de fls. 218, em favor da União, porque evidenciada a vinculação com o tráfico de drogas, bem como a destinação direta ao Funad/Senad, nos termos do artigo 63 da Lei de Drogas, oficiando-se, após o trânsito em julgado.

Quanto ao dinheiro apreendido com o réu FELIPE (R\$ 80,00), constante no auto de exibição/apreensão de fls. 24/25 e depósito judicial de fls. 218, em face da desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para uso próprio, autorizo que lhe seja restituído o numerário, após o trânsito em julgado.

Cobre-se a multa e a taxa judiciária, se forem devidas, de acordo com as NSCGJ.

Para se evitar, ao menos por ora, a intimação pessoal dos sentenciados, dê-se vista imediatamente ao Ministério Público e à Defensoria Pública e intimem-se os Defensores constituídos pelo DJE, a fim de que se manifestem acerca de eventual recurso.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Marília, 29 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA